

1500768-67.2022.8.26.0360
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Sansão Ferreira Barreto
Comarca: Mococa
Foro: Foro de Mococa
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 29/09/2022
... do Superior Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mococa
Foro de Mococa
1ª Vara
Avenida Doutor Gabriel do Ó, 1203, Mococa-SP - cep 13732-620
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500768-67.2022.8.26.0360 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500768-67.2022.8.26.0360
Classe - Assunto:
Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2182844/2022 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 25978821 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2182844 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
CARLOS EDUARDO DA SILVA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sansão Ferreira Barreto

Vistos.

CARLOS EDUARDO DA SILVA, já qualificado nos autos em epígrafe (fls 07), foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, pois como consta os inclusos autos de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante, que no dia 06 de julho de 2022, por volta de 17h00min, no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e Bahia, no bairro Vila Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Mococa, agindo em conjunto e com identidade de propósitos com o adolescente Otávio Augusto de Souza, mantinha em depósito e guardava, para entrega a consumo de terceiros (tráfico), 241 (duzentas e quarenta e uma) porções da droga popularmente conhecida como cocaína, totalizando, aproximadamente, 101,6g e 06

(seis) porções da droga popularmente conhecida como maconha, totalizando, aproximadamente, 363,8g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 27 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 75/77).

Apurou-se que policiais civis receberam informações anônimas que versavam sobre o denunciado e o adolescente Otávio.

Diante de tais informações, policiais civis realizaram vigilâncias veladas, com viaturas descaracterizadas, no local indicado, que se trata de um terreno baldio. Durante as campanhas, constatou-se que o denunciado e o adolescente estavam comercializando drogas, sendo que ambos serviam aos usuários e recebiam o dinheiro da transação, bem como guardavam e buscavam as drogas no esconderijo, localizado no referido terreno.

No dia dos fatos, a equipe policial logrou abordar o denunciado e seu comparsa quando adentravam no terreno baldio. Em poder do denunciado foi localizada a quantia de R\$ 30,00 e, em poder, do adolescente, a quantia de R\$ 86,00 e 02 (duas) porções de maconha.

Não bastasse, foram apreendidas, enterradas no terreno utilizado como esconderijo, 241 (duzentas e quarenta e uma) porções de cocaína, embaladas em pinos e plástico transparente, 04 (quatro) porções a granel de maconha, para serem posteriormente divididas e comercializadas, além de 62 (sessenta e dois) microtubos vazios. A quantidade e o modo de acondicionamento das drogas, bem como as demais circunstâncias narradas na denúncia, evidenciam que elas pertenciam ao denunciado e se destinavam ao comércio ilícito, exercido juntamente com menor de 18 anos. A denúncia (fls. 84/87) veio instruída com os autos de inquérito policial, sendo recebida no dia 06 de setembro de 2022 (fls. 109/112). O réu constituiu advogado com poderes a ele conferido (fls. 35), tem-se a conclusão inequívoca de sua ciência sobre o processo criminal a qual responde. Defesa prévia (fls. 90/96).

Durante a audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento das testemunhas arroladas na peça acusatória. E, ao final, o réu foi interrogado, tudo pelo sistema da tele audiência.

Encerrada a instrução processual, as partes manifestaram em sede de alegações finais orais, gravadas pelo sistema de tele audiência.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a presente ação penal deve ser julgada PROCEDENTE.

A autoria e materialidade do delito estão devidamente demonstradas através do auto de prisão em flagrante (fls. 01); do boletim de ocorrência (fls. 22/24); do auto de exibição/apreensão (fls. 27); do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 29); da fotografia (fls. 28); da requisição IC substância (fls. 30); da requisição IC objeto (fls. 31); e do laudo pericial químico-toxicológico (fls. 75/77). Bem como pelas provas produzidas nos autos.

O acusado CARLOS EDUARDO DA SILVA, em solo policial (fls. 7), informou que: Neste ato encontra-se acompanhado de sua advogada Dra. Mirella Garofalo Magri Chagas, OAB/SP nº 260.217, com escritório Rua Alcindo de Figueiredo, nº 488, São Domingos, Mococa/SP. Não deseja comunicar familiares, vez que sua mãe tem conhecimento de sua prisão. Que não possui filhos. Com relação aos fatos nega a prática de tráfico de drogas. Informa que trabalhou em sua casa a tarde toda. Esclarece que após terminar os afazeres em sua residência desceu até a esquina para soltar pipa. Que quando ali estava veio a ser abordado por policiais civis. Que outro indivíduo que estava na esquina também foi abordado. Que este indivíduo chama-se Otávio, mas o interrogando o conhece apenas de vista. Que com o interrogando foi localizada a quantia de R\$ 30,00, valor este fruto de seu trabalho, nada mais. Esclarece que ouviu um dos policiais informar que maconha teria sido encontrada com Otávio. Que nada tem a ver com as drogas apreendidas no terreno, próximo onde o interrogando estava. Nega a prática do tráfico de drogas. Novamente informa que nada de ilícito foi encontrado

em sua posse.

Em juízo disse que estava trabalhando no dia, e estava ajudando o pedreiro, que foi embora por volta das 16h30. Pegou a pipa e desceu um pouco para empiná-la. Nesse momento uma comionete veio e abordou. E o puxaram para a beira de um terreno. Não tinha nada consigo. E nem tinha costume de entrar nesse terreno. Só via o menor de vista, e nem tinha amizade com ele. Naquele local sempre tinha bastante movimento. Ficava muito ali próximo quando fumava maconha. O pedreiro lhe deu cinquenta reais, e havia entregado vinte reais para sua mãe ir a padaria.

A versão do acusado restou isolada no conjunto probatório e não merece credibilidade.

O adolescente OTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA, em solo policial (fls. 5), na presença da conselheira tutelar Deise Cristiani Gonçalves Gilioli informou que: Nesta oportunidade ciente dos fatos manifestou o desejo de permanecer calado para somente se pronunciar em Juízo. No tocante aos seus familiares estes estão cientes de sua prisão, mas ninguém quis acompanhá-lo.

O policial civil CESAR AUGUSTO SERIDONIO, em solo policial (fls. 2), informou que: em relação aos fatos tem a esclarecer que em razão de denúncias anônimas vinham sendo realizadas diligências na cidade de Mococa, na companhia de outros policiais civis e da Autoridade Policial, Dr. Wanderley, com a finalidade de apurar eventual tráfico de drogas que estaria ocorrendo no local dos fatos; Que há cerca de uma semana vem sendo realizadas vigilâncias veladas em horários diversos, com uso de viaturas descaracterizadas no local dos fatos, onde vinha sendo observado o ora autuado Carlos e o Adolescente Infrator Otávio comercializando drogas no local, sendo que ambos serviam aos usuários, como recebiam o dinheiro da transação; Que como o local dos fatos é um terreno baldio, difícil era abordar os usuários, pois qualquer movimentação diferente os traficantes como usuários empreendem fuga e dificilmente são alcançados; Que a vigilância ainda permitiu observar o local de esconderijo das drogas, ou seja, neste terreno baldio, onde sempre se dirigiam os investigados para se apoderar das porções e servirem os usuários; Que hoje foi possível abordar Carlos e Otávio quando adentravam a este terreno baldio e em poder de Carlos localizado o valor de R\$ 30,00, enquanto o adolescente OTAVIO trazia consigo R\$ 86,00 em moeda corrente e duas porções de maconha; Que até continuo ao vasculharem o terro baldio, precisamente onde se dirigiam os investigados, acabaram localizando enterrado 241 porções de cocaína, embaladas em pinos e plástico transparente, como mais 04 porções a grande, de maconha para serem posteriormente dividas, além de 62 microtubos vazios; Que o adolescente Otávio já tem outras passagens por tráfico de drogas e há cerca de seis meses deixou a fundação Casa, enquanto Carlos não apresenta passagens pelo delito em questão; Que diante dos fatos foi proferida a voz de prisão em flagrante delito e apreendido o adolescente.

O policial civil EVALDO ARMANDO ANTONIALLI, em solo policial (fls. 4): Em relação aos fatos tem a esclarecer que em razão de denúncias anônimas aportadas nesta Unidade Policial Especializada, vinham sendo realizadas diligências na cidade de Mococa, na companhia de outros policiais civis e da Autoridade Policial, Dr. Wanderley, com a finalidade de apurar eventual tráfico de drogas que estaria ocorrendo no local dos fatos; Que há cerca de uma semana estavam sendo realizadas vigilâncias veladas, com uso de viaturas descaracterizadas no local dos fatos, onde foi observado o ora autuado Carlos e o Adolescente Infrator Otávio comercializando drogas no local, sendo que ambos serviam aos usuários, como recebiam o dinheiro da transação, agindo em comum acordo; Que como o local dos fatos é um terreno baldio, uma esquina da Vila Santa Maria, difícil era abordar os usuários como os traficantes, pois qualquer movimentação diferente empreendiam fuga e dificilmente seriam alcançados; Que a vigilância ainda permitiu observar o local de esconderijo das drogas, ou seja, neste terreno baldio, onde sempre se dirigiam os investigados para se apoderar das porções e servirem os usuários; Que hoje foi possível abordar Carlos e Otávio quando adentravam a este terreno baldio e em poder de Carlos localizado o valor de R\$ 30,00, enquanto o adolescente OTAVIO trazia consigo R\$ 86,00 em moeda corrente e duas porções de maconha; Que até continuou ao vasculharem

o terreno baldio, precisamente onde se dirigiam os investigados, acabaram localizando enterrado 241 porções de cocaína, embaladas em pinos e plástico transparente, como mais 04 porções a grande, de maconha para serem posteriormente dividas, além de 62 microtubos vazios; Que o adolescente Otávio já tem outras passagens por tráfico de drogas e há cerca de seis meses deixou a fundação Casa, enquanto Carlos não apresenta passagens pelo delito em questão; Que diante dos fatos foi proferida a voz de prisão em flagrante delito e apreendido o adolescente.

Em juízo os policiais disseram que estavam recebendo delações de que dois indivíduos estavam fazendo o trafico de drogas, e fizeram campana no local e puderam perceber ambos, o acusado e o menor Otávio, revezando-se na entrega de drogas aos usuários. Foram abordados, e com o réu encontraram trinta reais, e com o menor oitenta e seis reais e duas porções de maconha embaladas para venda. No local onde ambos buscavam as drogas, num muro, encontraram 141 porções de cocaína, cem porção em plástico transparente, quatro porções a granel de maconha, além de sessenta e dois microtubos vazios para serem preenchidos com cocaína. Fizeram campana por cinco dias, na parte da tarde, e nesse periodo viram ambos revezando-se na entrega das drogas aos usuários. As denúncias aportaram por uma semana aproximadamente. Disseram que o réu morava proximo ao local da abordagem. Não abordaram usuários pois estavam apenas em dois policiais.

A testemunha Gustavo da Silva Marciano disse que cresceu junto com o acusado, mas não trabalha próximo dele. Nunca o viu mexendo com tráfico de entorpecentes. Também não sabe se ele é usuário de entorpecente.

A testemunha Rogério Fernandes do Nascimento disse que conhece o acusado há sete anos, e nunca ouviu falar dele vender drogas.

As provas são firmes para a condenação.

Gize-se que os policiais que participaram da diligência apresentaram relatos firmes e coerentes, sobre os fatos e acontecimentos, servindo de base para a elucidação do caso em tela.

Ressalte-se, por oportuno, que não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime.

Nesse sentido:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição".

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Pois bem.

Primordial trazer à baila a quantidade exorbitante de entorpecentes que se encontrava enterrada, pertencentes ao denunciado e ao adolescente, sendo aproximadamente 101,6 gramas de "cocaína", em 241 porções, divida em 141 eppendorfs e 100 porções dividas em plásticos transparentes; bem como aproximadamente 363,8 gramas de "maconha", em 06 porções, dividida em 04 porções grandes (granel) e 02 porções pequenas prontas à comercialização, segundo consta no auto de exibição e apreensão fls. 27 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 75/77.

Á vista disso, é límpido que o acusado desfruta da comercialização ilegal de drogas como modo de vida, corroborando com as demais circunstâncias que envolvem o presente caso, não oportunizam lacunas para entendimento diverso.

Salienta-se que o réu manteve em DEPÓSITO e GUARDOU drogas no terreno baldio, no qual usava como esconderijo, verbos nucleares esses, tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Importante ressaltar que no momento da abordagem do denunciado, foi apreendido com o mesmo, a quantia de R\$ 30,00 (trinta) reais e, em poder, do adolescente, a quantia de R\$ 86,00 (oitenta e seis).

Cumprе enfatizar que as substâncias entorpecentes, segundo estudos, agem diretamente no sistema nervoso. Com isso, do ponto de vista científico, considerando que o bem jurídico tutelado pelo crime disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006 é a saúde pública, consequentemente, para que a natureza da droga seja considerada grave, tal constatação deve se basear em informações sobre a nocividade de cada entorpecente para a saúde de seu usuário, como danos gerados nos órgãos, grau de dependência, agressividade no indivíduo, portanto, não há dúvidas em relação à autoria do delito de tráfico de drogas.

Ademais, se tem reiteradamente decidido que para a caracterização do delito previsto no artigo 33, não se faz necessário seja o infrator colhido no próprio ato da vendada mercadoria proibida. Tratando-se de crime de mera conduta, ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo, não importa a modalidade, dessa forma, basta que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal.

Segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020)”.

Não obstante, é importante frisar que policiais civis receberam informações anônimas que versavam sobre o denunciado e o adolescente, diante disso, realizaram vigilâncias veladas, com viaturas descaracterizadas, no local indicado, que se trata de um terreno baldio. No qual constataram que o denunciado e o adolescente estavam comercializando drogas, ambos serviam aos usuários e recebiam o dinheiro da transação.

Portanto, entendo que há prova suficiente e segura de que o réu estava voltado à prática do repulsivo delito de tráfico de drogas que, no mais das vezes, impulsiona a prática de outros crimes de natureza grave, como homicídio, roubo, tráfico de armas e outras coisas mais.

Á vista do exposto, o acusado deverá ser obrigatoriamente condenado, não podendo ocorrer à absolvição, caso contrário a Justiça estará agindo não por motivo de direito, mas sim por mera conveniência.

Destarte, provadas a materialidade e a autoria, a condenação é de rigor.

Dito isso, e atento às diretrizes dos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, dada a quantidade, variedade e natureza da droga cocaína, é o caso de atração do art. 42 da Lei 11.343/06. Além disso, a culpabilidade é mais acentuada, pois realizava o tráfico de drogas próximo da própria residência, também apresentou versão mentirosa em juízo, com o objetivo de afastar a imputação.

Como cediço, a integridade do sistema judicial depende da participação honesta e sem medo de represálias de todos os envolvidos em um caso que esteja sendo

investigado ou processado.

Mentir ao juiz, tentar constranger uma testemunha, encorajar ou participar da destruição de provas, intimidações e retaliações de toda natureza contra quem participa de um processo, interferência de maneira inadequada no trâmite das investigações ou no trâmite processual são exemplos claros de obstrução da justiça no direito norte americano.

Observo que o réu, em seu interrogatório, tem a livre autonomia para trilhar três caminhos. Pode ele confessar a prática do crime, contribuindo com a "busca da verdade real" e, conseqüentemente, com a Justiça, fato que implicará na redução de sua pena, por força da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Pode, também, ficar em silêncio, fato que não resultará em qualquer prejuízo para ele.

No entanto, caso resolva falar perante o Juiz, jamais poderá mentir, pois a lei não lhe confere tal "direito", cabendo a ele, tão somente, dizer a verdade, pois às partes é exigível o dever de lealdade processual. Dessa forma, caso opte pela mentira, com nítida intenção de induzir o julgador em erro, deve sua pena-base ser majorada, com fundamento em sua personalidade negativa (CP, art. 59), pois reveladora de um caráter distorcido, de ausência de senso moral e de uma índole desviada.

Oportuno, neste ponto, transcrever a crítica de NELSON HUNGRIA ("A diagnose da mentira" in Novas Questões-Jurídico Penais, Editora Nacional de Direito, 1945, p. 233), que já asseverava, com grande veemência, "que, desgrazadamente, a mentira é um dos mais constantes fatores de perturbação da Justiça Criminal ou um dos mais eficientes recursos tendentes à impunidade dos que delinquem. Sempre foram fiéis aliados o crime e a mentira".

Por outro lado, é certo que o direito ao silêncio, facultado ao réu a fim de evitar que se autoincrimine (nemo tenetur se detegere), encontra respaldo na Constituição Federal (CF, art. 5º, LXIII). Todavia, dele jamais se pode extrair o direito de mentir, pois a mentira representa verdadeira fraude processual, não podendo o Estado ser complacente com este tipo de comportamento vil e abjeto, que pode levar ao erro judiciário, desmoralizando, assim, a própria Justiça.

Nessa esteira preleciona FIGUEIREDO DIAS (in Direito Processual Penal, Coimbra Editora, 2004, p. 450), ao afirmar de forma contundente que o entendimento que defende ao acusado o exercício de um suposto direito de mentir deve ser repudiado. Afinal, nada existe na lei que possa fazer supor o reconhecimento de tal "direito".

Como ensina Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): "Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar – até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica –, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente".

Ora, como a mentira tem por escopo iludir os jurados, ludibriar o "ex adverso", enganar a coletividade e provocar um erro judiciário, tal circunstância negativa sobre a personalidade do acusado será sopesada pelo juiz-presidente na fixação da pena, nos termos do art. 59 do CP.

Nesse sentido:

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do

acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade" (Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017).

"...demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

"Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base..." (Apelação nº 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto).

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras." (Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação nº 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva).

"Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça" (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019; 6.ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decisum que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo "fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime" (TJSP – Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15.ª Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP – Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8.ª Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos

termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372, 1ª Vara Judicial de Hortolândia - Juiz de Direito, Luis Mário Mori Domingues j. 21.01.2015.

“E escoreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”, demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida. (Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 10.12.2019; Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625).

Por tais razões, fixo a pena base do crime em 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no piso.

Na segunda fase, está presente a atenuante da menoridade relativa, e por isso reduz a pena em 1/6 (um sexto), e por isso retorno a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, pois restou demonstrado que o acusado realizava o tráfico juntamente com o adolescente Otávio, e por isso majoro a pena em 1/6 (um sexto).

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico a impossibilidade de seu reconhecimento, tendo em vista que a prova deixa claro que o réu não preenche os requisitos exigidos, pois foi detido em circunstâncias que evidenciam o anterior envolvimento com tráfico de drogas, há pelo menos uma semana, tempo do período da realização da campanha policial.

Isso porque durante o monitoramento os policiais disseram que era a grande movimentação de usuários no local. Além disso, a denúncia que deu ensejo a diligência já era de mais de uma semana, denotando que não era neófito ou ocasional.

Portanto, não se trata de traficante eventual ou de pequeno traficante, dada a quantidade de droga apreendida, a justificar a redução da pena como se pode ver.

Nesse sentido, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra do i. Desembargador Geraldo Wholers (Apelação nº 0427092-39.2010.8.26.0000 - 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo):

“O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente 'não se dedique às atividades criminosas'. Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de

isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico”

No mesmo sentido é o entendimento do i. Des. Sérgio Ribas (Apelação nº 0001509-68.2017.8.26.0616 – 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo):

“Não se pode olvidar, visa a lei, dentre outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à sociedade, pelas razões inversas.”

Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras dos réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Ressalto que não há qualquer inconstitucionalidade no tipo legal do tráfico, ou mesmo em seu preceito secundário, uma vez que a própria Constituição Federal estabelece um maior rigor contra os crimes hediondos e aos equiparados a estes. Tratando-se de crime equiparado a hediondo, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, sendo o regime fechado o único compatível para atender as finalidades de prevenção e repressão da pena.

Neste ponto, cumpre trazer à baila brilhante lição sobre o tema, em acórdão da lavra o i. Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan (Apelação nº 0014063-92.2015 – 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo):

“O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. Outro regime seria insuficiente para a reprovação de tráfico dessa monta. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui, sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nas sessões ordinárias dessa E. Câmara, sempre em número superior a 500 feitos, são referentes a tráfico de drogas. Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancrios da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios”.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força do art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo fato de que não estão preenchidos os requisitos objetivos do art. 44 do CP.

Por fim, no que concerne a aplicação do contido no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observa-se que a detração de pena se trata de matéria cuja apreciação é de competência exclusiva do Juízo das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial específica, não obstante reforma parcial do Estatuto Adjetivo tenha estabelecido a matéria no artigo em comento.

E nem poderia ser diferente, uma vez que apenas o MM. Juiz das Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de condenações do apelante, aí incluídas todas as suas eventuais execuções, como também o seu histórico comportamental, na condição de recluso, decorrendo dessa análise a possibilidade, ou não, de ser a ele deferida eventual progressão de regime prisional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu: CARLOS EDUARDO DA SILVA. RG 53.413.842, nascido aos 22/4/2002, filho de Jair da Silva e de Cleusa da Silva, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso; por incursos no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão.

As provas trazidas para os autos dão conta de que os valores apreendidos decorrem e servem à traficância e, por tais motivos, decreto o perdimento em favor da União, devendo-se a transferência ao FUNAD, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado para as partes, lancem-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo V, itens 30 e seguintes das NSCGJ) e mandados de prisão. No mais, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ). Custas 'ex lege'.

Destaco ser incabível o reconhecimento da detração penal, uma vez que se trata de matéria afeta à execução criminal, sede natural para análise dos requisitos exigidos pela lei.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Mococa, 29 de setembro de 2022.

- Sansão Ferreira Barreto -
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA